

1501270-15.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2021, por volta das 00h15min, na Rua Santo Antônio nº 90, no Distrito de Cruz das Posses, comarca de Sertãozinho, os réus produziam, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 930,72g (novecentos e trinta gramas e setenta e dois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501270-15.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501270-15.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2145910/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 18203602 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 1379/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2145910 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 1379/21/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE JOSÉ DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

HENRIQUE JOSÉ DA SILVA, JOÃO PEDRO CAIRES DOS SANTOS e EDUARDO DE MORAIS TERRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da lei nº 11.343/06, porque, em data incerta, porém até o dia 29 de maio de 2021, por volta das 00h15min, na Rua Santo Antônio nº 90, no Distrito de Cruz das Posses, comarca de Sertãozinho, Henrique se associou com João

Pedro e Eduardo, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2021, por volta das 00h15min, na Rua Santo Antônio nº 90, no Distrito de Cruz das Posses, comarca de Sertãozinho, os réus produziam, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 930,72g (novecentos e trinta gramas e setenta e dois decigramas) de pasta de Cocaína, acondicionadas em 01 (um) invólucro plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, os réus se associaram para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, dividindo as tarefas entre si para consecução da mercancia ilícita de drogas. Para tanto, passaram a utilizar a residência de Henrique como uma espécie de laboratório para preparo e embalagem de Cocaína para posterior distribuição, com a utilização de produtos químicos previamente adquiridos. Enquanto Henrique cedia, a título oneroso, a morada para o armazenamento e preparo do entorpecente, pelo valor diário de R\$ 70,00 (setenta reais), os réus João Pedro e Eduardo transportavam o entorpecente até o local e se responsabilizavam pelo embalagem e preparação das drogas. Ocorre que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da residência de Henrique, momento em que vislumbraram João Pedro e Eduardo saindo desse imóvel e dirigindo-se ao veículo de placas EUP-6717, com tarjeta do município de Tabatinga, que estava estacionado defronte ao local. Outrossim, sentiram forte odor de produtos químicos, tais como: éter, acetona e álcool, comumente utilizados para refino de entorpecente, que exalava do interior da residência. Diante da suspeita de que no local estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas, os policiais militares decidiram abordar os dois homens que saíram do local. Indagados a respeito, ambos confessaram informalmente aos policiais que "alugavam" a residência de Henrique, pelo valor diário de R\$ 70,00 (setenta reais), para o armazenamento e refino de entorpecente. Nesse momento, os agentes estatais ouviram o acionamento da descarga e ingressaram na residência e, no interior do banheiro depararam-se com Henrique, e dentro do vaso sanitário encontraram uma porção grande de pasta base de Cocaína. Em revista pessoal, localizaram nas vestes de Henrique a quantia de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais). Ato seguinte, vistoriaram a cozinha e encontraram diversos petrechos comumente utilizados para o refino de drogas, além de um fogareiro. Questionado, Henrique confessou que cedia o imóvel, há pelo menos 01 (um) mês, aos acusados João Pedro e Eduardo, como "laboratório" e para o armazenamento e refino do entorpecente, e afirmou que recebia, a título de contraprestação, a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) ao dia. A denúncia foi recebida em 02 de julho de 2021 (fls. 131/132). Os réus foram citados (Henrique - fls. 147; Eduardo - fls. 149 e João Pedro - fls. 200) e apresentaram defesa prévia (Henrique - fls. 197/198; Eduardo - fls. 150 e João Pedro - fls. 214/221). Durante a instrução, foram colhidas as declarações de duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas pela Defesa de Eduardo, sendo os réus interrogados ao final. Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, absolvendo-se os réus João e Eduardo dos crimes que lhes são imputados, bem como o réu Henrique, com relação ao crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, condenando-o, contudo, como incurso no artigo 33, caput, da mesma Lei Federal. (fls. 271/278). As Defesas dos réus Eduardo e João Pedro requereram a absolvição, por falta de provas. Em cenário de condenação, pediram penas mínimas, a serem executadas em regime menos severo, tendo a Defesa de João Pedro ainda requerido, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele do art. 28 da Lei de Drogas e o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 280/281 e 285/293). A Defesa de Henrique requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação das penas mínimas, do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e a absolvição em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas (fls. 294/301). É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte, impondo-se a condenação do acusado Henrique pelo delito previsto no preceito primário do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e sua absolvição em relação ao delito previsto no art. 35 da mesma legislação. No tocante aos acusados João Pedro e Eduardo, impõe-se a absolvição em relação a todos os delitos descritos na peça acusatória.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 15/16 e 17/18), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 20/21), pelas imagens fotográficas (fls. 19), pelo laudo pericial (fls. 111/113, 114/121, 182/186 e 191/196) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao denunciado Henrique, também é inconteste. Vejamos a prova colhida.

Os policiais militares Lázaro e Paulo, na fase policial, disseram que em patrulhamento de rotina, pelo distrito de Cruz das Posses, observaram 02 indivíduos, saindo da residência, local dos fatos, e se dirigindo para um veículo de placas EUP-6717, Tabatinga. Dentro da casa, podia-se sentir um forte cheiro de produtos químicos, utilizados no refino de entorpecentes, quais sejam, éter, acetona e álcool. Os policiais narraram que os réus lhes disseram, informalmente, que alugaram a casa pelo valor de R\$ 70,00 (setenta reais) e estavam refinando entorpecentes por lá, onde neste momento ouviu-se o som de descarga, tendo os policiais adentrado na residência e presenciado Henrique no banheiro e uma quantidade de pó branco (Cocaína) dentro do vaso sanitário. Fora também encontrado nas vestes do réu Henrique o valor de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais). Os apetrechos utilizados no refino de drogas ilícitas foram encontrados agrupados na cozinha, além de um fogareiro. O réu Henrique, proprietário da residência, disse aos policiais militares que o entorpecente era dos investigados e cedia a residência, ganhando o valor de R\$ 70,00 (setenta reais) (fls. 06/07).

Em Juízo, o policial Paulo disse que viu dois homens deixando uma casa e indo em direção a um carro com emplacamento incomum, que estava bem próximo da residência. Disse que também sentiu forte cheiro de éter vindo da residência acima mencionada. Ao abordar os homens, na calçada, ouviu deles que no local ocorria refino de drogas. Após serem autorizados por João e Eduardo, disse que entraram na casa e viram Henrique dando descarga em uma quantidade de drogas. Disse que ouviram a descarga ainda fora da casa, e quando entraram viram que o vaso já estava entupido, sendo que o entorpecente foi retirado com pás e colheres. Relatou ainda que com Henrique foi encontrada a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), ouvindo dele a explicação de que era tal quantia vindoura da locação da casa para Eduardo e João refinarem drogas, sendo aquela a terceira vez que a locação ocorria. Apreenderam éter e vários outros itens de refino de Cocaína. Disse que já conhecia Eduardo e João de outras abordagens, em Sertãozinho. Relatou que procuraram por mais entorpecentes em cima de árvores e em telhados mais baixos, posteriormente à abordagem dos réus. Ressaltou que com Eduardo e João nada de ilícito foi encontrado.

Em Juízo, o policial Lázaro disse que estava em patrulhamento, por volta das 00h00min, quando ele e seu parceiro avistaram um carro com placa diferente das demais. Ao iniciarem abordagem, referente ao veículo, viram também que João e Eduardo estavam entrando no referido carro. Relatou que realizaram abordagem, então, em ambos e, sentiram forte cheiro de éter vindo deles e da casa ao lado, local do qual os réus Eduardo e João estavam saindo. Indagando os réus, souberam que no local havia um laboratório para refino de drogas. Disse que foram autorizados por João e Eduardo a entrarem na casa, e quando entraram, viram Henrique dando descarga em uma grande quantidade de droga. Disse que Henrique confirmou que locava o ambiente para refino de drogas. Disse que apreenderam éter, fogareiro, utensílios para fabricação e drogas (v. mídia).

A testemunha Isabel, arrolada pela Defesa do réu Eduardo, em Juízo, disse que o réu é namorado de sua neta, frequenta sua residência, e na data dos fatos, chegou no local por volta de 6 horas, e segundo o réu disse, um amigo ligou pedindo para buscá-lo em Cruz das Posses, por volta de 10h40min (v. mídia).

A testemunha Letícia, arrolada pela Defesa do réu Eduardo, em Juízo, disse que não conhece o réu. Relatou que na data dos fatos, por volta das 00h00, policiais diligenciaram em sua casa, buscando entorpecentes, porém nada foi encontrado. Quanto aos fatos, nada soube informar (v. mídia).

O réu João Pedro, interrogado na fase policial, disse que estava tomando um chopp, quando entrou em contato com Eduardo, tendo este lhe dado uma carona com seu carro, quando foi abordado por policiais militares. Explicou que estava transitando juntamente com Eduardo, desconhecendo o réu Henrique e muito menos os entorpecentes apreendidos, afirmando não praticar comércio ilícito de entorpecentes (fls. 08). Em Juízo, disse que não conhece Henrique, mas é vizinho de Eduardo e o conhece desde a infância. Disse que estava com uma menina, e se distraiu, perdendo o ônibus para voltar para Sertãozinho. Pediu para Eduardo ir buscá-lo, e se encontrariam na primeira rua da cidade. Asseverou terem sido abordados nesse momento e foram postos dentro da viatura. Disse que os policiais então andaram dois quarteirões adiante, parando em frente à referida casa. Narrou que os policiais revistaram outras casas (v. mídia).

O réu Eduardo, interrogado na fase policial, disse que estava na casa de sua namorada, quando recebeu uma ligação de seu amigo João Pedro pedindo para que o interrogando o buscasse em Cruz das Posses, pois aparentemente ele (João Pedro) havia perdido o ônibus. Narrou que pegou João Pedro e foi abordado pelos Policiais Militares. Alegou que não é traficante e negou conhecer Henrique (fls. 09). Em Juízo, negou a acusação. Disse que saiu do trabalho e foi à casa da namorada. Por volta de 10h40min, João Pedro, que mora em sua rua, ligou dizendo que tinha perdido o ônibus, para voltar de Cruz das Posses. Disse que foi buscar João por volta das 11h10min ou 11h20min. Verbalizou que João estava com uma menina. Ao chegar na cidade, ligou para o amigo e disse que estava esperando no início da cidade. João já estava descendo, oportunidade em que os policiais o abordaram. Os policiais revistaram o carro, assim como outras casas nas proximidades, porém nada foi encontrado. Aduziu que nada foi encontrado com ele, mas mesmo assim ele e João foram colocados na viatura e levados para outro local, defronte uma casa que nunca tinha visto. Disse que foi levado para 03 quarteirões de distância de onde estava primeiramente (v. mídia).

O réu Henrique, interrogado na fase policial, disse que apenas cede a sua residência para utilizarem como local de produção de droga. Disse ainda que não é traficante, porém sabe o que faz é ilegal. Confessou que cede sua residência como laboratório há cerca de um mês e que recebe, por dia de utilização, a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais). Apesar da confissão, o réu disse que não reconhece os outros acusados como os que utilizam a sua casa para a produção de drogas (fls. 10). Em Juízo, disse que não reconhece Eduardo e João como os locatários da casa e alegou que não os conhece. Disse que morava na casa há duas semanas, sendo que antes residia com sua irmã. Disse que residia na casa também pagando aluguel de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Narrou que durante a abordagem, estava tomando banho.

Esclareceu que estava guardando drogas desde o dia anterior, sendo que ganharia R\$ 100,00 (cem reais) pelo serviço e ainda um pedaço da droga (v. mídia).

Diante desta prova, reputo inexistir prova segura do envolvimento dos réus João Pedro e Eduardo com o tráfico.

Não obstante a narrativa dos policiais militares, no sentido de que os acusados João Pedro e Eduardo confessaram, informalmente, terem alugado o imóvel pertencente ao corréu Henrique para fins de fabricação de drogas, não há nos autos elementos probatórios colhidos em instrução regular a corroborar tais relatos, situação esta bem posta nas alegações finais do órgão ministerial.

As versões apresentadas pelos acusados Eduardo e João Pedro são coerentes, ratificadas pelas testemunhas arroladas pela Defesa e corroboradas pelas informações prestadas pelo corréu Henrique em seus interrogatórios na fase policial e durante a fase processual.

O cabedal probatório confirma que os denunciados Eduardo e João Pedro possuem relação de amizade de longa data, sendo que na data dos fatos João Pedro solicitou auxílio do amigo para busca-lo na cidade de Cruz das Posses com destino a Sertãozinho, pois teria perdido o último horário do transporte público. Logo após

terem embarcado no veículo conduzido por Eduardo, os agentes de segurança fizeram a abordagem, mas nada de ilícito foi localizado com eles, porém, por estarem na proximidade de uma residência com indícios de ocorrência de ilícito relacionado ao tráfico de drogas, foram relacionados ao acusado Henrique como associados para o tráfico de drogas.

Observe-se que, afora a versão dos policiais, a única ligação entre os denunciados Eduardo e João Pedro com o delito confessado pelo acusado Henrique seria a circunstância de que estariam próximos, na data dos fatos, à residência objeto da apreensão das drogas. Além disso, em declarações feitas na fase policial e processual, o denunciado Henrique asseverou não conhecer nenhum dos outros corréus. Ademais, inexistem provas de que os acusados tenham sido flagrados anteriormente juntos em situação que fizesse presumir envolvimento associativo para comércio de entorpecentes.

Desta forma, não há base probatória para prolação de decreto condenatório em relação aos acusados Eduardo e João Pedro. Por via de consequência, não evidenciado vínculo associativo, com estabilidade e permanência, outrossim, inexistente a figura do delito de associação para o tráfico de drogas prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 para todos os denunciados.

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão, em relação ao delito previsto no art. 33, "caput", do SISNAD, cujo autoria e materialidade convergem para o réu Henrique.

Os policiais militares narraram unissonamente que, em patrulhamento de rotina, logo após abordar os acusados João Pedro e Eduardo, sentiram forte odor de substâncias que são comumente utilizadas para produção de mercadoria ilícita exalando do imóvel pertencente ao acusado Henrique. Os policiais afirmaram, ainda, que o réu Henrique estava dando descarga em um pó branco, quando foi abordado, dentro da residência.

O próprio réu Henrique confessou na fase policial que alugava sua casa para servir como laboratório de drogas e que tinha total consciência de que seus atos eram ilegais. Em Juízo, também admitiu que guardava o entorpecente apreendido.

Ademais, dentro da residência foram encontrados os apetrechos utilizados no refino de drogas ilícitas, agrupados na cozinha.

Assim sendo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado nos autos que o réu Henrique tinha drogas em depósito para comercialização, assim como as produzia ou permitia que produzissem e fabricassem drogas para a venda, condutas estas que configuram o delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

A destinação da droga à comercialização se concluir pela significativa quantidade apreendida (930,72g de pasta base de cocaína), somado ao fato de que petrechos destinados ao refino e embalo também foram encontrados no local.

Assim, reputo que a acusação formulada na denúncia, relativamente ao réu Henrique, foi devidamente confirmada em parte pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu Henrique como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu Henrique no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Na segunda fase, verifico que o réu Henrique é confesso, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que a pena seja reduzida aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque, além da grande quantidade de droga, foram apreendidos diversos outros petrechos indicativos de que o réu atuava não somente no armazenamento e comercialização, mas também no preparo da droga, posto que também encontraram no imóvel grande quantidade de fármacos, a exemplo de éter etílico, bem como balança de precisão.

Pontue-se, por oportuno, que embora não tenha restado configurado o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, situação que, por si só, seria suficiente para afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016), é da confissão do réu Henrique a cessão remunerada de seu imóvel para fins de armazenamento e refino de drogas, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada. O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma

supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu Henrique, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, ressalto que o acusado foi flagrado pelos policiais militares na posse e mantendo guardada significativa quantidade da droga Cocaína (quase 1kg de pasta base), sendo esta substância grande portadora do potencial de causar rápida dependência e o réu ainda não comprovou, de forma idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, com indicativos de que atuava de forma regular no tráfico, posto que também apreendido em sua posse fármacos e petrechos destinados ao preparo da droga para comercialização, a merecer ser duramente apenado.

E pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de

direitos, nego ao réu Henrique o direito de recorrer em liberdade, ainda mais porque permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu HENRIQUE JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, bem como para ABSOLVÊ-LO da prática do delito do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e também para ABSOLVER os réus JOÃO PEDRO CAIRES DOS SANTOS e EDUARDO DE MORAIS TERRA, qualificados nos autos, da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Não há que se falar em detração para fins de fixação de regime inicial mais brando, conforme previsto no art. 387, § 2º, inserido pela Lei 12.736/12 porque, para obtenção deste benefício é necessário, além da verificação do tempo de prisão, também a análise de requisito subjetivo, o que deve ser apurado pelo Juízo da execução.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 08 de março de 2022

Angel Tomas Castroviejo  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA